

1502082-23.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente traga consigo o entorpecente, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu:

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502082-23.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502082-23.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241695/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 27200413 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2241695 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2241695 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JENNIFER MANTOVANI DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

JENNIFER MANTOVANI DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de setembro de 2022, às 10h, na Rodovia SP 334, 323, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiro, nas

dependências de estabelecimento prisional, drogas consistentes em, 71,400g (setenta e um gramas e quatrocentos miligramas) de "COCAÍNA" em pó, acondicionadas 01 (um) invólucro de plástico incolor aderente.

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2022 (fls. 75/76).

A acusada foi citada (fls. 65) e apresentou defesa prévia (fls. 68/71).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha em comum e, ao final, a ré foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o I. Representante do Ministério Público requereu a procedência integral da ação penal.

A Nobre Defesa, por sua vez, pleiteou pela improcedência da ação penal. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da lei 11.343/06 (fls.93/95).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade da infração está comprovada pelo auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6); Boletim de Ocorrência (fls.11/13); pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16); pelo Laudo do IML (fls. 38/39); pela Fotografia (fls.21); pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls.33/34); pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls.54/55), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e indubitosa.

A ré, em fase inquisitiva, declarou que é a amásia de Valmir dos Santos Vasconcelos, que cumpre pena na CPP de Jardinópolis pelo Tráfico de Drogas e que foi coagida pelo recluso a levar a droga até a unidade prisional, vez que ele chegou a ameaçar seus filhos. Informou que durante o procedimento para a visitação de reclusos, enquanto submetia-se a scanner a agente penitenciária verificou algo em sua região pélvica. Frisou que retirou a droga espontaneamente e entregou ao agente. Salientou que a droga foi entregue por pessoa desconhecida e que não sabia informar qual droga foi apreendida em seu poder. (fls. 09). Em juízo, disse que era usuária de drogas, e ofereceram dinheiro para que levasse as drogas para o CPP, e por abstinência aceitou. Salientou que seu companheiro não tinha ciência dos fatos, pois estava em isolamento na enfermaria. Afirmou que nunca foi presa ou processada antes dos fatos. Informou que trabalha como faxineira. Explicou que era usuária de drogas, mas não utiliza mais, para passar um bom exemplo para seus filhos menores. Salientou que trabalha realizando faxina, e que suas patroas não tem conhecimento dos fatos. Afirmou que parou de utilizar drogas sem qualquer tratamento. Relatou que não há ninguém para cuidar de seus filhos, e que para realizar faxina, paga uma babá para cuidar de seus filhos.

As testemunhas de acusação, agentes penitenciários, Sandra Cristina Midon Marcondes e Kleber Henrique Romeiro Alves, em ambas as fases, relataram, em consonância, que, encontravam-se em serviço durante o procedimento de entrada de visitas na unidade prisional, quando através do scanner corporal, verificaram que a indiciada, visitante do recluso Valmir dos Santos Vasconcelos, apresentava um volume suspeito na região pélvica. Diante disso, conduziram a indiciada até o banheiro, onde veio a retirar espontaneamente o objeto e informou que levaria tal substância ao reeducando Valmir e que participou tal ato pois estava sendo coagida por ele.

Salientaram que a substância apreendida aparentava tratar-se de pasta base de cocaína. (fls. 07 e 089, respectivamente).

A testemunha comum, Valmir dos Santos Vasconcelos, em juízo, negou ter qualquer conhecimento sobre a conduta de sua companheira, pois tinha estado internado nas últimas duas semanas em razão de herpes, motivo pelo qual não tinha tido qualquer contato com a ré, não tendo conhecimento sobre os fatos, dizendo por fim, que talvez sua companheira estivesse passando por dificuldades financeiras, razão pela qual deve ter aceito levar as drogas para outro detento do Centro de Progressão Penitenciária.

Diante de tão robusto conjunto probatório, formado pelas firmes e seguras palavras dos agentes penitenciários, corroboradas pela declaração da ré, não há como cogitar-se a absolvição por insuficiência de provas.

Embora os policiais não tenham visto a ré entregando drogas a terceiros, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos "(...) trazer consigo (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente traga consigo o entorpecente, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu:

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Destarte, não há como desclassificar a infração para o delito previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, até mesmo porque não foi trazido à baila nenhum elemento capaz de afastar as robustas provas existentes nos autos no sentido de que a infração foi cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais.

Assim, é robusto e harmônico o conjunto probatório, para a condenação da ré.

Observo que com relação ao destino que seria dado à droga, não há nenhum dado seguro que me permita concluir que seria a venda. Por outro lado, as evidências colhidas nos autos indicam que a droga seria entregue a consumo, gratuitamente e sem autorização ao recluso Valmir dos Santos Vasconcelos, restando certo a classificação do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não há provas suficientes nos autos que fundamentem ou demonstrem que os entorpecentes seriam destinados à comercialização e não ao uso pessoal do recluso, principalmente pelo modo que a droga foi apreendida.

No mesmo sentido se fez os depoimentos dos agentes penitenciários, os quais relataram, em consonância, que durante abordagem foi constatado pelo scanner que a denunciada apresentava um volume suspeito na região pélvica.

Não há nenhum motivo que faça desmerecer os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários em Juízo.

O fato de serem as testemunhas, agentes penitenciários, por si só, não desabonam seus depoimentos, pois não têm nenhum motivo para incriminar a ré. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos

presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

Os agentes penitenciários não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo suas funções. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade dos atos realizados pelos policiais, de suas alegações serem ratificadas por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por serem estes agentes públicos que têm, no exercício de suas funções, presunção juris tantum de que agem correta e validamente. De mais, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM – SP 43/251; 50/218 – 219).

Ademais, na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307).

Em mesmo sentido, Mirabete preleciona que: “A palavra 'flagrante' é derivada do latim, flagrare (queimar) e flagrans, flagrantis(ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria” (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356).

Dessa forma, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.

Necessário evidenciar que nas ocasiões em que a confissão do acusado ocorreu de

forma livre e sem contradição, esclarece e convence no mais alto grau a consciência do juiz, pois, se é prova corroborada com outros elementos nos autos, torna-se suficiente para embasar uma decisão condenatória.

Nesse sentido:

Prova. Confissão judicial. Valor. - "A confissão é meio de prova cujo sentido valorativo é apreciado diante de sua natureza. Se judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador, e somente perderá sua força se desmentida pelas provas restantes" (TACRIM-SP - 12ªC.- AP 133.586-7/4 - Rel. Luiz Ganzerla - j. 28.07.2003 - Rolo/flash 2010/377).

Assim sendo, a condenação da acusada pelo crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, é medida de rigor.

III. Dosimetria da Pena

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis à ré, pois não possui indícios de maus antecedentes, motivo pelo qual fixo a pena no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segunda fase, ausentes causas agravantes e, embora presente a causa atenuante estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, no que diz respeito à confissão espontânea do agente, esta não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho o quantum supramencionado.

Na terceira fase, vislumbro causa de aumento de pena conforme artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, neste diapasão, aumento em 1/6 a pena da acusada. No entanto, observo que o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, prevê uma causa de diminuição de pena, a qual deve ser aplicada ao caso em tela, tendo em vista que não há notícias nos autos de que a ré integre organização criminosa, e pode se recuperar, tornando-se útil à sociedade, além de não possuir maus antecedentes e ser primária. Posto isso, diminuo o quantum supramencionado em 2/3, perfazendo um total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso legal.

Por fim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso legal.

Não se faz cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no artigo 44, do Código Penal, devido a pena ser superior a quatro anos. Da mesma forma, não faz jus ao benefício do sursis previsto no artigo 77, do Código Penal.

Deverá a acusada iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea c, do Código Penal, c.c. o parágrafo 3º deste mesmo artigo. Isto porque a jurisprudência nos tribunais superiores (e até mesmo em parte do E.TJ/SP) firmou entendimento de que a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas enseja tal benefício, não se tratando de crime hediondo e não havendo óbice à aplicação pura e seca do art. 33 e seguintes do Código Penal. Além disso, há de se considerar a Súmula 440 do STJ.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal a fim de CONDENAR a acusada JENNIFER MANTOVANI DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso legal.

Em face da condenação arcará a ré com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiária da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA